

1501194-21.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR

Comarca: Paraibuna

Foro: Foro de Paraibuna

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... dos réus pelo crime de associação ao tráfico de drogas e suas condenações pelo crime de tráfico de drogas, com a fixação de regime fechado e sem a possibilidade de substituição por restritivas de direitos (fls. 170/173). Por outro lado, a I. Defesa, em sua alegação final oral, pugnou pela aplicação da pena mínima, o reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraibuna

Foro de Paraibuna

Vara Única

Rua Major João Elias Calazans, 565, . - Centro

CEP: 12260-000 - Paraibuna - SP

Telefone: (12) 2138-2453 - E-mail: paraibuna@tjisp.jus.br

1501194-21.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501194-21.2021.8.26.0617

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUANA FATIMA DE MOURA e outro

Vistos.

LUANA FATIMA DE MOURA e DANIEL ELIAS SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 c.c. os artigos 29 e 69 do Código Penal.

A acusação é de que, em 01 de setembro de 2021, por volta das 20h46min, na Rua Projetada, 22, Centro, nesta cidade e Comarca de Paraibuna, LUANA FATIMA e DANIEL transportavam e guardavam, para fins de comercialização ilícita, 25 porções contendo o total de 26,42g de cocaína, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 29/30, laudo de constatação provisória de fls. 21/26 e laudo de exame químico-toxicológico juntado a fls. 122/123, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Anteriormente aos fatos acima descritos, LUANA e DANIEL associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Nos dizeres da denúncia, os réus se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. Na data dos fatos, DANIEL conduzia o veículo GM/Corsa Wind, cor vermelha, placas BSI-1310, pela Rua Projetada, Bairro Alferes Bento, levando como passageira sua namorada LUANA, que trazia consigo, guardava e transportava a droga acima descrita. Nessa ocasião, todavia, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o veículo dos réus e determinaram a sua parada. Durante a abordagem, os policiais suspeitaram da postura de LUANA, que demonstrou nervosismo ao desembarcar do carro. Os policiais, então, abordaram o réu e nenhum bem ilícito foi encontrado em poder dele ou no interior do veículo. LUANA, entretanto, retirou as vinte e cinco porções de cocaína que estavam ocultas em seu sutiã e as entregou aos policiais militares. Indagados, os réus admitiram que pretendiam revender as drogas no Bairro Alferes Bento, pelo preço de R\$ 20,00 cada invólucro. Os policiais também encontraram a quantia de R\$ 5,00, que estava na carteira de DANIEL. Os réus, então, foram presos em flagrante delito. A narcotraficância restou demonstrada pela quantidade de droga, a forma como estava disposta, em porções individuais e prontas para a venda, bem como pelas próprias confissões dos réus.

A denúncia (fls. 154/156) foi instruída com o inquérito policial de fls. 01/150.

Os acusados foram notificados, apresentaram defesa prévia e a denúncia foi recebida aos 15 de abril de 2019 (fls. 166/167, 184, 186, 194/195 e 198/199).

Na audiência de instrução e julgamento (art. 57, Lei nº 11.343/06), duas testemunhas de acusação foram inquiridas, os réus foram interrogados e as partes fizeram suas alegações finais orais (fls. 231/232)

Os extratos pertinentes e relevantes das inquirições das testemunhas de acusação e interrogatórios dos réus são:

Marcos Antônio Schmitz (testemunha de acusação/policial militar): Estavam em patrulhamento ostensivo pelo bairro, quando avistaram o veículo Corsa vermelho. Realizaram a abordagem, e em revista ao motorista foi encontrado apenas R\$ 5,00. No interior do veículo não havia nada de ilícito. Indagou a passageira LUANA, para que passasse o celular, o que foi negado. Perguntou à passageira se ela estava com drogas, o que foi negado em um primeiro momento. Informou à passageira que seria acionada uma policial feminina para realizar a revista. Nesse momento, LUANA tirou de seu sutiã, algumas porções de drogas. Indagou novamente se havia mais drogas em seu poder, e a passageira retirou mais drogas do mesmo local, totalizando vinte e três porções de cocaína. Ambos admitiram que estavam com realizando o tráfico pela cidade, há mais ou menos um mês, por dificuldades financeiras. A droga seria entregue para desconhecidos ali no bairro. E cada porção seria vendida por R\$ 20,00. Não tinha conhecimento de que eles eram namorados. Conhecia apenas a passageira de vista. Os dois são moradores de Paraibuna. Havia denúncias de que os dois realizavam tráfico de drogas.

Carlos Eduardo Pedroso (testemunha de acusação/policial militar): Estavam em patrulhamento pelo Bairro Alferes Bento e se depararam com um veículo com os faróis apagados, o que motivou a abordagem. Já havia informações acerca de um casal realizando o tráfico pelo bairro. As denúncias davam conta de que usuários mandavam mensagens para o casal, que ia de carro realizar a venda dos entorpecentes. Foi realizada a busca pessoal no Daniel, sendo encontrado apenas R\$ 5,00. No veículo nada de interesse foi encontrado. Indagaram LUANA se estava com algo de ilícito, o que foi negado em um primeiro momento. Pediram o celular, e ela se recusou a entregar. Informaram que uma policial feminina viria de Jacareí para realizar a busca pessoal, e nesse momento ela entregou algumas porções de entorpecente. Questionaram se havia mais, o que foi negado por Luana. Informaram que ela seria conduzida até a Delegacia, onde uma policial feminina iria realizar uma revista completa, sendo que nesse momento ela entrou o restante das drogas. As drogas

estavam no sutiã de LUANA. Os dois admitiram o tráfico, disseram que estavam ali para fazer entregas, e que a droga seria vendida por R\$ 20,00 a unidade. Tinha conhecimento que eles eram um casal. Havia denúncias que eles realizavam o tráfico, mas foi a primeira vez que os abordaram.

LUANA FÁTIMA DE MOURA (ré): Tem dois filhos, um de 4 anos e outro de 2 meses. Trabalhou por seis anos na Padaria Pão Perfeito. Na época dos fatos estava trabalhando. Somente o filho mais novo é do DANIEL. Moram juntos desde a época dos fatos. Estudou até a 8ª Série. Os fatos descritos na denúncia são verdadeiros. Estava com as drogas escondidas no seio. DANIEL está dirigindo o veículo nesse dia. Estavam no Bairro Alferes Bento. Falou para os policiais que estava com as drogas, mas por necessidade, em vista dos filhos pequenos e todas as despesas da casa. O filho estava sem fraldas e leite. Não fazia muito tempo que estavam vendendo drogas. Não tem nada contra os policiais e nunca respondeu a outro processo criminal.

DANIEL ELIAS SILVA (réu): Trabalha como motoboy e servente. Estudou até o segundo colegial. LUANA é sua companheira. Moram juntos desde o ano passado. Tem um filho com LUANA. Não tem outros processos criminais. No dia dos fatos, os policiais realizaram a abordagem, mas não foi da forma como relatada por eles. Eles chegaram apontando a arma na nossa cara. Eles nos tiraram do carro e me revistaram. LUANA não foi revistada. Ela negou estar com as drogas em um primeiro momento, mas depois acabou entregando. Estavam muito apertados em casa, por isso iriam vender as drogas. Não estavam vendendo há muito tempo. A ideia de vender as drogas partiu do casal, porque era dinheiro fácil.

Em sua sustentação oral, o Ministério Público analisou as provas produzidas e pleiteou as absolvições dos réus pelo crime de associação ao tráfico de drogas e suas condenações pelo crime de tráfico de drogas, com a fixação de regime fechado e sem a possibilidade de substituição por restritivas de direitos (fls. 170/173). Por outro lado, a I. Defesa, em sua alegação final oral, pugnou pela aplicação da pena mínima, o reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto e substituição por pena alternativa, diante da confissão do réu e por não estar envolvido em atividades criminosas.

É o breve relato do que importa.

DECIDO.

I- Crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Ab initio, importa asseverar que o delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 exige o dolo específico dos agentes no sentido de formar uma associação estável e permanente para fins de traficância. De acordo com jurisprudência, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, a expressão "reiteradamente ou não", inserida no tipo, não pode levar ao entendimento de que o crime dispensa a demonstração da permanência ou estabilidade dos associados.

Neste sentido, tem-se:

Superior Tribunal de Justiça.

DIREITO PENAL. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Dessa forma, é atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual). Precedentes citados do STF: HC 64.840-RJ, DJ 21/8/1987; do STJ: HC 166.979-SP, DJe 15/8/2012, e HC 201.256-MG, DJe 29/6/2012. HC 139.942-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em

19/11/2012. (STJ, Informativo n. 0497, período: 7 a 18 de maio de 2012).

In casu, prova alguma nos autos foi produzida, mormente a oral, a indicar uma associação estável entre LUANA e DANIEL, para a finalidade de tráfico de drogas.

De fato, os policiais militares, ouvidos em Juízo, nada esclareceram sobre outros tráficos praticados pelos dois réus, muito menos mencionaram alguma associação permanente deles para o tráfico, não podendo se presumir que, por serem um casal, também estariam associados para a prática deste crime.

Neste contexto, a absolvição dos réus por esta imputação penal é medida que se impõe, ante ao princípio in dubio pro reo.

II- Delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade (existência) do delito de tráfico ilícito de drogas e suas autorias em relação aos increpados DANIEL e LUANA sobejaram-se demonstradas pelas provas documental, pericial e oral amealhadas nestes autos.

O auto de exibição e apreensão de fls. 29/30 indica que, por ocasião das prisões em flagrante delito dos réus, foram apreendidas 25 porções contendo substância assemelhada a cocaína em pó, R\$ 5,00 em dinheiro, dois celulares e um automóvel.

O laudo de constatação apontou resultado positivo para cocaína para as substâncias apreendidas, cujo peso total líquido foi de 16,8 gramas.

O laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 122/123 detectou cocaína nas porções apreendidas, substância listada na Portaria 344/1998 SVS/MS - Lista F1 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil).

Os policiais militares, inquiridos sob o crivo do contraditório, disseram que, no dia dos fatos, abordaram os réus trafegando pelo bairro Alferes Bento em Paraibuna, a corré LUANA estava com as porções de cocaína escondidas no sutiã, os dois réus confessaram que as drogas eram para a venda e que já havia informações de que um casal estaria vendendo drogas no bairro.

Isso não bastasse, os réus admitiram o tráfico de drogas, sob a justificativa de dificuldade econômica.

A propósito, as confissões dos réus estão em consonância com o conjunto probatório amealhado nos autos, de modo que servem para embasar o reproche penal, conforme regra do art. 197 do CPP.

Assim, pode-se afirmar, com segurança, que os réus praticaram o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, diante do conjunto coeso de provas diretas e indiretas colhidas nos autos.

Passo a dosar a pena, com fundamento no art. 5º, XLVI, da CF e na forma do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 68 do CP.

A cocaína possui alto grau de nocividade para a saúde pública, em virtude do grande poder entorpecente e de dependência química desta droga. Todavia, a quantidade desta droga foi muito pequena (16,8 g de peso líquido total das cocaínas encontradas com a corré LUANA), de modo que se revela muito desproporcional exasperar a pena pela natureza da droga. A quantidade total das drogas apreendidas não deve influir na dosimetria da pena, porque foi pequena. Não há elementos desabonadores às suas condutas sociais e personalidades (circunstâncias preponderantes - art. 42 da Lei 11.343/06). Os acusados não possuem antecedentes criminais. A culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências foram

normais ao tipo penal. Inexiste especial comportamento da vítima para influir na pena. Sopesadas as diretrizes estabelecidas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59, do Código Penal, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Igual tratamento deve ser adotado no tocante à sanção pecuniária.

Sobre a pequena quantidade de droga de alto poder viciante na dosimetria da pena, tem-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora a natureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena (a teor do que enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006) e não obstante a natureza da substância trazida pelo acusado - cocaína - seja, realmente, dotada de alto poder viciante, a quantidade de substância apreendida - 0,48 gramas - é muito pequena, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base. 2. O Magistrado não apontou nenhum elemento concreto dos autos que, efetivamente, justificasse o porquê da conclusão de que o réu, efetivamente, se dedicaria, com certa frequência e anterioridade, ao tráfico de drogas, motivo pelo qual está evidenciada flagrante ilegalidade capaz, inclusive, de ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer, em seu favor, a incidência de minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 3. Uma vez que o agravado foi condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, era tecnicamente primário ao tempo do delito, possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base estabelecida no mínimo legal e foi beneficiado com a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal, com observância também ao preconizado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. A favorabilidade das circunstâncias mencionadas evidencia que a substituição da pena se mostra medida socialmente recomendável, de acordo com o art. 44, III, do Código Penal, motivo pelo qual deve ser determinada a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 570.587/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

As confissões dos acusados serviram de alicerce para suas condenações, no entanto, inviável a aplicação da atenuante disposta no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal, pois a pena-base foi fixada em seu mínimo legal (Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça).

Não há outras atenuantes ou agravantes a serem apreciadas.

Os réus devem ser agraciados pela causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), porque são primários, de bons antecedentes e não se dedicam às atividades criminosas nem integram organização criminosa. A redução da pena deve ser na razão máxima, qual seja, 2/3.

A propósito, sabe-se que "No tocante ao tráfico privilegiado, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição" (STJ, HC 523503/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, T5, DJe 22/10/2019). Todavia, a quantidade da droga apreendida foi ínfima, de modo que seria irrazoável deixar de aplicar o patamar máximo previsto nesta causa de diminuição da pena.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Assim, estabelece-se a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Tendo em vista as condições econômicas dos réus, até mesmo por falta de prova em contrário quanto à viabilidade em fixar quantia superior, o valor diário da pena pecuniária corresponde ao mínimo previsto pelo artigo 43, da Lei nº 11.343/06.

Reconhecido o privilégio, não incide no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estabelece como regra o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.

Em 23.06.2016, ao julgar o "Habeas Corpus" nº 118.533/MS, de Relatoria da Ministra Carmen Lúcia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou a natureza hedionda do tráfico privilegiado de entorpecentes. Na ocasião, o Ministro Edson Fachin salientou que, para se qualificar delito como hediondo e equiparado, é indispensável que haja previsão legal e estrita. "Como desdobramento do princípio da legalidade, de intensa aplicação na seara penal, considera-se que o rol dos crimes elencados na lei 8.072/90 é de caráter estrito, ou seja, não admite ampliação mediante analogia."

E ainda que assim não fosse, o mesmo órgão já declarou, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, autorizando o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, conforme as disposições do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Desta forma, não há impedimento legal no presente caso para a concessão do regime aberto, desde o início, até porque a Lei de Drogas não faz nenhuma referência ao regime inicial, devendo-se aplicar a regra geral estabelecida no Código Penal.

Sendo assim, considerando o quantum de pena imposta, aliado à primariedade do réu, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixa-se o regime inicial aberto para o seu cumprimento.

Por fim, cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por se revelar suficiente para a prevenção e reprovação do delito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Com efeito, estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, porquanto os acusados são primários, todos os requisitos do inciso III são favoráveis (a natureza da droga - art. 42, Lei de Drogas - somente obstará este benefício, caso demonstre, juntamente com a quantidade, ser esta substituição insuficiente) e não se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça.

De mais a mais, adequada ao caso a substituição, pois a aplicação do redutor demonstra menor culpabilidade e, conseqüentemente, merecimento.

Assim, substituo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, e multa no mesmo patamar da pena principal, nos termos do parágrafo segundo (segunda parte), art. 44, do Código Penal, porque os critérios do inciso III, deste artigo, são favoráveis ao réu.

Neste sentido, tem-se:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa que visa a manutenção da figura do tráfico privilegiado com a redução da pena em seu patamar máximo. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais civis

uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso. 2. Dosimetria que merece reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 231 do STJ. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Manutenção da figura do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo. Manutenção do regime prisional aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 3. Recurso conhecido e provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500655-35.2020.8.26.0344; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022)

Ante o exposto e o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido acusatório, para ABSOLVER os réus LUANA FATIMA DE MOURA e DANIEL ELIAS SILVA, qualificados nos autos, de terem cometido o crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo penal; e CONDENÁ-LOS a cumprirem a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso mínimo previsto no artigo 43 da Lei nº 11.343/2006, por praticarem o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser fixada no Juízo da execução, atendendo-se o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso mínimo previsto no artigo 43 da Lei nº 11.343/2006.

DECRETO o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 29/30), nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/2006, porque foi apreendido no mesmo contexto do tráfico e não foi demonstra a origem lícita do numerário.

Por outro lado, DETERMINO a liberação do veículo apreendido e os dois celulares, uma vez que não ficou provado que serviram de instrumentos para a prática do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no Rol dos Culpados.

Publique-se. Intimem-se.

Paraibuna, 15 de dezembro de 2022.

PEDRO FLÁVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR
Juiz de Direito
(Assinatura Eletrônica)